

1500372-92.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... natureza e quantidade da droga, apreensão de petrechos destinados ao tráfico, além da administração de um apartamento utilizado como depósito para o narcotráfico), o regime inicial de cumprimento será o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º, do Código Penal.

Trata-se de condenação por tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500372-92.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-92.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Clésio Francisco da Silva

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Clésio Francisco da Silva foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 21 de março de 2022, por volta das 11h, nas proximidades do Condomínio Ipê, Novo Horizonte, e na Avenida João Ramalho, nº 109, Bloco 18, apartamento 02, Bonfim, ambos em Taubaté, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e tinha drogas em depósito para fins de tráfico.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, no primeiro endereço acima mencionado, o réu tinha consigo, para fins de tráfico, duas porções de cocaína acondicionadas em pequenos tubos plásticos do tipo "eppendorf", três porções de crack e onze porções de maconha. Já em sua residência, o réu mantinha em depósito outras noventa e duas porções de cocaína acondicionadas da mesma forma. Somado a isso, escondidas em uma cama, o réu mantinha outras duas porções maiores, ainda a granel, de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão e tubos plásticos vazios, comumente utilizados para acondicionar a cocaína para a venda.

Na data dos fatos, policiais acabaram por abordar o réu. Submetido à revista pessoal, com ele foram encontradas e apreendidas as drogas que trazia consigo. Após ter admitido a posse de mais entorpecentes em sua residência, o acusado franqueou a entrada dos policiais ao imóvel. No local, os agentes efetuaram buscas e encontraram o restante da droga e os petrechos para seu manuseio, prendendo o réu em flagrante delito.

Na residência do réu foram apreendidos, ainda, dois aparelhos de telefone celular e a quantia de R\$ 143,00, produto do narcotráfico.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 74/76.

Citado (fls. 111), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 120/121.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ressaltou que não houve nenhuma irregularidade na ação policial, conforme relatado pelos policiais, que afirmaram terem se dirigido à residência do réu após ele ter assumido a posse das drogas e somente com a autorização para o ingresso no imóvel. Anotou que, em data anterior, houve tentativa de realização de buscas no local, todavia, depararam-se com a negativa do proprietário, motivo pelo qual não executaram a diligência, fato que traz credibilidade aos depoimentos. Nesse cenário, sustentou que o réu não foi sincero em seu interrogatório, a fim de viabilizar a absolvição ou mesmo a aplicação de pena mais branda. Enfatizou que, como se observa nas conversas extraídas do aparelho celular apreendido em poder do réu, ele estava praticando o tráfico pelo menos desde meados de 2020, data da primeira conversa registrada. Aduziu que em uma das mensagens há negociação para ele assumir uma “loja” responsável pela venda de entorpecentes. Portanto, defendeu ser evidentemente mentirosa a afirmação de que não estaria na posse de drogas quando da sua abordagem e, ainda, que apenas estaria eventualmente guardando o entorpecente. Na dosimetria, vislumbrou circunstâncias desfavoráveis, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida, devendo a pena-base ser exasperada. Na segunda fase, não vislumbrou agravantes, sendo que eventuais atenuantes não podem ser utilizadas para reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Na terceira fase, considerando a constatação da prática habitual do tráfico de drogas, em especial pelas mensagens constatadas no aparelho de telefone celular, alegou ser inaplicável o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por último, diante das circunstâncias desfavoráveis, pediu a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

A Defesa requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, sustentado a ilicitude do conjunto probatório produzido. Afirmou ser inequívoco o fato de que as drogas foram apreendidas no apartamento ocupado pelo réu. Contudo, o ingresso na residência foi feito em desconformidade com o disposto nos artigos 241 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e em manifesto descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, reiterou a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que não há nos autos provas suficientes a uma condenação. Ressaltou que o réu negou que tivesse drogas consigo quando abordado. Informou, ainda, que o ingresso dos policiais ocorreu logo após terem localizado a chave em seu pescoço, sem qualquer menção à posse de entorpecentes. Nesse sentido, anotou que a versão dos policiais vem desamparada de

qualquer lastro mínimo de segurança, uma vez que não indicaram quem seriam os demais indivíduos abordados e não apontaram qualquer testemunha presencial. Destacou que ambos narraram uma solicitação anterior de mandado de busca e apreensão para o apartamento que suspeitavam ser local de armazenamento de drogas. Aduziu que as testemunhas não se recordaram de qualquer informação que tenha sido mencionada expressamente nessa suposta denúncia. Nesse cenário, pontuou que a versão do réu se mostrou mais crível e verossímil, considerando que ele narrou a existência de entorpecentes no imóvel e justificou que estava residindo no local em razão das dificuldades financeiras. Discorreu, ainda, que as mensagens telefônicas que teriam se originado do celular do réu não foram objeto de questionamento em juízo, sendo impossível garantir que ele era o único autor dos textos. Deve ser considerado, ainda, que, de acordo com os policiais, havia ao menos mais quatro pessoas na oportunidade, que poderiam ter emprestado o aparelho. Caso o entendimento não seja este, havendo condenação pelo delito de tráfico, solicitou que a pena seja fixada no piso mínimo legal. Destacou que a quantidade de drogas apreendida e o contexto da localização impedem eventuais considerações sobre quantidade e variedade. Enfatizou que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não havendo qualquer investigação sobre seu envolvimento de forma habitual ou sua dedicação ao tráfico, asseverou que a aplicação do privilégio se mostra medida de rigor. Defendeu que os policiais informaram que o réu colaborou com as investigações e negaram conhecê-lo anteriormente. Diante das circunstâncias do caso, pleiteou a aplicação de regime inicial aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pediu que seja facultado eventual apelo em liberdade e a dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de tráfico de drogas, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade das provas por violação de domicílio. Afirmo que os policiais invadiram a residência do réu, local onde foram encontradas as drogas apreendidas, sem motivo justificável ou mandado judicial para tal fim. Dessa forma, entende que a prova não pode ser utilizada em desfavor do réu por ser ilícita.

A arguição preliminar, com devida vênia, não procede.

Do conjunto probatório se verifica que, no caso, a diligência policial não atentou contra inviolabilidade domiciliar, porquanto os policiais estavam em patrulha decorrente de apuração de homicídios quando decidiram abordar quatro pessoas que estavam na região dos fatos. Disseram os milicianos que apenas o réu trazia drogas consigo, mais especificamente maconha, cocaína e crack, todas individualmente embaladas e prontas para comércio. Informaram que o réu confessou a posse das drogas e que mantinha outros entorpecentes em sua casa, permitindo o acesso da equipe policial. Aduziram localizaram e apreenderam diversas porções de drogas no imóvel, além de efetuarem a abordagem de outro indivíduo, o qual confessou que sabia que o imóvel era utilizado para esconder drogas.

Dessa forma, a prova constante dos autos é suficiente a demonstrar que havia elementos seguros, objetivos e racionais a justificar a entrada no domicílio sem o respectivo mandado, mas mediante autorização do investigado. Presente estava, ali, a justa causa, consubstanciada no estado de flagrância do réu vislumbrado pelos agentes policiais.

Com efeito, os policiais ouvidos no curso do processo informaram de forma uníssona que o acesso à residência foi autorizado pelo próprio réu.

Nada obstante, o ingresso na residência foi precedido do encontro de drogas em poder do acusado, submetido à busca pessoal na via pública, e, nas circunstâncias, havia fundado motivo para que os policiais acreditassem que havia mais drogas na residência do réu, o qual inclusive prontamente declinou tal informação aos milicianos.

Não se pode perder de vista que o crime de tráfico de drogas constitui crime permanente, de forma que o agente pode ser preso em flagrante enquanto possuir entorpecentes para esse fim (tráfico ilícito), podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade do domicílio, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Tal entendimento é consagrado na doutrina e na jurisprudência e foi novamente referendado em recente decisão do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 213852, AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022) – original sem destaque.

Assim, a prova colhida não está maculada pela invasão de domicílio, diligência que se fez com a guarida da lei e com respaldo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“PRELIMINAR - nulidade da prova em face da invasão de domicílio - inocorrência - fundada suspeita consistente na visualização do réu em local apontado pela denúncia anônima e com as características indicadas pelo denunciante - fuga do réu após avistar a guarnição policial - guarda de entorpecente que configura estado flagrancial - afastada a preliminar. MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga na residência do réu – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - versão do réu de que a residência diligenciada não era sua - versão que não restou demonstrada. TRÁFICO – destinação a terceiros – quantidade, incomum com a figura do usuário; forma de

acondicionamento da droga, própria para a venda a varejo; apreensão de dinheiro; e denúncia anônima - de rigor a condenação do réu - improvemento ao apelo (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501914-97.2019.8.26.0571; Relator (a): Mens de Mello; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga; Data do Julgamento: 25/01/2022)

A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo em auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 16/19), termo de depoimento (fls. 3/4), termo de interrogatório (fls. 11), auto de qualificação e vida pregressa (fls. 12), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 24/28), laudo pericial (fls. 115/118) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Ricardo Faura Simões, ouvida em juízo, relatou que estava em diligências pelo bairro CECAP, em torno de um conjunto de apartamento. Contou que estava procurando uma motocicleta utilizada na tentativa de duplo homicídio. Ao se aproximar, notou dois indivíduos. Disse que Clésio carregava consigo algumas porções de drogas, as quais seriam destinadas à venda. Pontuou que o réu carregava chaves de um apartamento, apesar de não residir no local. Asseverou que o acusado abriu o imóvel e permitiu o acesso dos policiais. Aduziu que encontrou outras porções de drogas no imóvel, assim como petrechos e eppendorfs. Disse que havia outra pessoa no imóvel, em um dos quartos nos quais foram localizadas porções vazias para armazenar drogas. Enfatizou que havia denúncia de um apartamento "bomba", mas não sabia da localização exata. Pontuou que a polícia tentou efetuar diligências anteriores no local, mas houve erro de inteligência sobre o local e o mandado de busca foi indeferido. Não se recorda se os quartos estavam abertos.

A testemunha Cristiano José dos Santos informou que estava efetuando diligências na região dos fatos, pois houve denúncia de que envolvidos com uma tentativa de duplo homicídio estavam por ali. Abordou quatro indivíduos, mas apenas Clésio trazia consigo algumas porções de drogas. Durante breve entrevista, o réu falou que não era da região, mas estava vendendo drogas ali. Pontuou que o acusado disse que fazia uso de um apartamento por ali, o qual ele abriu e permitiu o acesso da polícia. Aduziu que havia outra pessoa no local. Em um dos quartos havia diversas porções de drogas e embalagens. No outro quarto, foi possível encontrar dentro da cama algumas porções de drogas, embalagens e uma balança. Não conhecia o acusado. Enfatizou que a polícia tinha informações sobre um apartamento "bomba" na região, mas não tinha certeza da exata localização. Acredita que havia cerca de R\$ 150,00 no quarto ocupado por Andrew. Não se recorda se os cômodos estavam com as portas trancadas. Disse que Clésio abriu a porta de entrada com as chaves que carregava consigo.

Interrogado, o réu disse que estava na companhia de outras três pessoas quando foi abordado. Confirmou que morava em outro condomínio, no bloco 18, onde havia uma denúncia de apartamento "bomba". Foi conduzido ao apartamento e os policiais abriram o local. Contou que os policiais renderam Andrew, que estava no apartamento. Afirmou que as portas dos quartos foram arrombadas. Não carregava drogas consigo. Aduziu que havia drogas no apartamento. Estava sem local para morar e buscou ajuda com um conhecido. Informou que aceitou permanecer no local sem pagar aluguel mediante o armazenamento de drogas. Relatou que um quarto ficava fechado com cadeado e somente o proprietário do imóvel tinha acesso. Havia recebido algumas porções de drogas dias antes. Disse que Andrew estava dormindo no local por alguns dias. Não comercializava drogas.

Bem provadas a autoria e a materialidade do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Observo que a conduta do réu se enquadra em ao menos dois dos verbos-núcleo do tipo, notadamente armazenar e trazer consigo drogas para fins de tráfico, resultando configurada a tipificação do crime em destaque.

A própria prisão em flagrante comprova que, somadas as porções que o réu trazia consigo e armazenava em sua casa, com ele foram apreendidos 234,09 gramas de cocaína, maconha e crack, drogas que seriam destinadas ao comércio direto a usuários (fls. 23/28).

Em adição à prisão em flagrante, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo com fidelidade o quanto afirmado durante a fase do inquérito, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado, dizendo como se deu a prisão e as demais circunstâncias em que foram encontradas as drogas com o réu.

Disseram que estavam efetuando diligências na região dos fatos, pois foi irradiada informação de que pessoas responsáveis pela tentativa de homicídio estavam ali. Informaram que apenas o réu, dentre outros três indivíduos, estava portando droga. Pontuaram que o acusado não morava na região, mas estava vendendo drogas ali. Aduziram que o réu informou utilizava um apartamento no local e permitiu o acesso da polícia. Disseram que havia outra pessoa no local, além de diversas porções de drogas, embalagens e uma balança. Enfatizaram que já tinham prévia ciência da existência de um "apartamento bomba" na região, mas não sabiam sua localização exata. Informaram que o réu abriu a porta do imóvel com as chaves que carregava consigo.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Somado à narrativa dos policiais, durante o inquérito policial, a testemunha Andrew disse que estava morando no imóvel palco dos fatos, pois fora expulso de casa. Contou que estava desempregado, mas Clésio permitiu que morasse no local por alguns dias. Já estava dormindo no local há cinco dias. Tinha plena ciência que o imóvel era utilizado para armazenar drogas. Disse que o réu Clésio vendia drogas.

Importante destacar que a quantidade e a natureza da droga, atrelada à presença de balança de precisão e embalagens destinadas ao fracionamento em porções individuais, dão conta da traficância exercida.

Quem é apanhado, como aqui, mantendo grande quantidade de droga escondida e atrelada a utensílios sabidos por se destinarem ao fracionamento e embalagem individual de entorpecentes, não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância.

Com relação à causa de diminuição de pena previstas no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observo que não é o caso de reconhecê-la.

De se anotar que a redução prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante, o fortuito. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

Veja-se que a grande quantidade de drogas, aliada aos diversos petrechos apreendidos na posse do réu obstam a aplicação do redutor justamente porque dão conta e são indicativos hábeis de que ele se dedica à atividade criminosa e a tem como meio de vida. Não se pode olvidar, ainda, que o réu confessou que estava utilizando o imóvel em favor de terceiros, efetivos proprietários das drogas armazenadas no local, o que demonstra seu vínculo com organizações voltadas ao crime, que não confiariam a quantidade de droga apreendida a quem não ostentasse relacionamento estreito e duradouro.

Não se pode olvidar, ainda, que as conversas extraídas do telefone celular apreendido na posse do réu corroboram a versão fornecida pelos policiais de que o acusado, de fato, estava comercializando drogas na região em que foi abordado. Analisando os documentos de fls. 199/208, 210/219 e 231/261, é possível concluir que o telefone pertencia ao réu e era por ele utilizado para negociar drogas.

Cumprir destacar, ainda, que o acusado também não comprovou a origem do dinheiro localizado em sua residência (fls. 67), fator que indica que faz do tráfico de drogas sua fonte de renda.

Analisadas as teses da acusação e da defesa, conclui-se que o réu era, na data dos fatos, imputável, e tinha plena consciência de seus atos, não concorrendo nenhuma das causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que pudessem elidir sua responsabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu guardava drogas para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo responder penalmente pelo ilícito praticado.

Passo, assim, à dosimetria da pena em obediência aos ditames do artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico de Nelson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A quantidade, a variedade e a natureza das drogas, parte com grande poder viciante, pesam em desfavor do réu. Conforme fundamentado, as diversas drogas estavam individualmente embaladas para difusão aos usuários finais e havia mais de duzentos gramas de maconha, cocaína e crack, as últimas de efeitos profundamente deletérios à saúde dos usuários (fls. 20/28).

O réu não ostenta maus antecedentes (fls. 40/42). Não há elementos para aferir sua conduta social.

A personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexactidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo “A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena”, da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com

má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no

momento que se pronunciam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisor que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3^a Vara Criminal, em sede de apelação

(Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base.” (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie. Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, à reprimenda mínima cominada em abstrato acresço 1/3, fixando a pena-base no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente qualquer agravante, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu tinha menos de 21 anos na data dos fatos. Assim, possível a diminuição da reprimenda, que passa a totalizar 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias, além de 555 dias-multa.

Em atenção à quantidade de pena imposta ao réu e às demais circunstâncias específicas do caso concreto (personalidade desvirtuada, natureza e quantidade da droga, apreensão de petrechos destinados ao tráfico, além da administração de um apartamento utilizado como depósito para o narcotráfico), o regime inicial de cumprimento será o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'a', e §

3º, do Código Penal.

Trata-se de condenação por tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado, cabendo ser ressaltado que por se cuidar de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime mais severo.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime e a reincidência do réu, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Inadmissível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei n. 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF, HC n. 89824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 28/8/2008; STF, HC n. 114536/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/12/2012; STJ, HC n. 222002/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013).

No caso concreto, o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do réu (artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de forma que, reputando presente a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos réus, nos termos acima explicitados, dá-se cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'.

Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registre-se que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos com o réu (fls. 67) em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Clésio Francisco da Silva à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA